

0004751-21.2011.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... impede que o réu incida na prática do crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, entende a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004751-21.2011.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004751-21.2011.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Roberto Gomes da Silva

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr.LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de janeiro de 2011, por volta das 8hs20, no interior da cela 220 do Pavilhão Celular II da penitenciária "João Batista de Santana", situada na zona rural do município de Riolândia, nesta Comarca, JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA, qualificado às fls. 37, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico no interior do aludido estabelecimento prisional, doze porções com massa total de 51,92g (cinquenta e um gramas e noventa e dois centigramas) de "maconha", sem autorização legal ou regulamentar, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo de fls. 12. Segundo se apurou, nas circunstâncias descritas o denunciado mantinha porções de drogas depositadas e ocultas no interior de uma antena que guarnecia a televisão da cela. Sucede que, durante revista de rotina, agentes de segurança penitenciária lá estiveram e localizaram-nas, apreendendo-as em seguida. Instado por eles, o denunciado admitiu a propriedade do entorpecente. Pela grande quantidade de drogas e pelo seu acondicionamento, em numerosas porções prontas para

a venda, resta evidente que seu destino era o tráfico no interior do estabelecimento prisional. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA, por infração ao artigo 33, "caput", c.c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e requeiro que, autuada esta, instaure-se o competente processo penal, conforme o rito dos artigos 54 e seguintes da Lei referida, intimando-se o denunciado para oferecer defesa preliminar e, após o recebimento da denúncia, seja submetido a interrogatório, ouvindo-se o rol abaixo arrolado e prosseguindo-se até final sentença e condenação.

A denúncia foi recebida em fls. 100/132.

O acusado foi notificado (fl. 107).

Apresentou defesa prévia (fls. 125-129).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 25 de agosto de 2014, foram ouvidas as testemunhas Ewerton César Uzeloto e Ademir Aranha Baleeiro, bem como interrogado o acusado (fls. 236-246).

Foi proferida sentença condenatória (fls. 248-251)

Irresignado, ao autor apresentou apelação (fls. 259-260/270-287)

Por sua vez, manifestou-se o Ministério Público em contrarrazões de apelação (fls. 288-291).

A superior instância anulou a retro sentença (fls. 311-318).

Com o retorno dos autos, houve a elaboração do laudo pericial a respeito de dependência química (fls. 343-346/420-423).

O Ministério Público reiterou as alegações finais apresentadas em audiência, consistente no pedido de que o acusado seja condenado nos termos da denúncia (fls. 382-383).

A defesa ofertou alegações finais, reiterando o pedido de absolvição por ausência de elementos probatórios que demonstrem a conduta ilícita do acusado e ainda a desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente (fl. 448).

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade dos delitos restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07-08), Autos de Exibição e Apreensão (fls. 12-13), Laudos Periciais (fls. 15-16/420-423) e Termo de Depoimento (fls. 18/19).

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

A testemunha Ademir Aranha Baleeiro, aduziu que participou da operação e confirmou que durante uma revista na cela do acusado a droga foi encontrada por Ewerton dentro da antena da televisão que ficava no local. Disse que estava do lado do Ewerton quando a substância foi localizada. Mencionou ter sido admitido pelo acusado que a droga era dele. Questionado pela defesa, aduziu que a revista era normal, de rotina. Disse não saber se o acusado comercializava a substância entorpecente.

A testemunha Ewerton César Uzeloto, narrou que estavam realizando revista de rotina na cela do acusado e encontrou a droga na base de uma antena. Declarou ter sido assumido pelo réu, presente no local, que a droga era dele. Questionado, aduziu que encontrou maconha, aproximadamente doze porções. Questionado pela defesa, aduziu não saber se o acusado comercializava o entorpecente.

Em seu interrogatório, o acusado informou que um dia antes da revista havia adquirido a droga para consumo próprio. Afirmou ser dependente químico. Detalhou que a quantidade apreendida é suficiente para fazer até 50 cigarros. Mencionou ter pago R\$150,00. Especificou que fumava dentro da cela enrolando a droga em um papel.

Destaco, de pronto, que os depoimentos dos agentes penitenciários retro transcritos se revestem de inequívoca validade, eis que colhidos em juízo sob o manto do princípio constitucional do contraditório e do devido processo legal. Ademais, os agentes não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado no exercício das funções. Assim cumpre dar validade aos depoimentos das testemunhas de acusação inquiridas no curso da instrução criminal. Essa é a orientação que se colhe da jurisprudência, como se infere da leitura da ementa do aresto que segue, in verbis:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016);

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS PROVA SUFICIÊNCIA Materialidade e autoria comprovadas Apelante flagrado no momento em que entregava estupefaciente para consumo do corréu, ambos custodiados em Penitenciária Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Provas incriminatórias consistentes Testemunha arrolada pela Defesa que não infirmou as responsabilidades penais dos acusados - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS VALIDADE Os testemunhos dos agentes penitenciários têm validade como quaisquer outros Depoimentos coerentes Condenação mantida Crimes configurados - Sentença condenatória mantida RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00105897920078260269 SP 0010589-79.2007.8.26.0269, Relator: Amado de Faria, Data de Julgamento: 15/12/2011, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/12/2011);

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - VALIDADE - FARTA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Estando provadas a materialidade e a autoria delitiva, verificando-se, ainda, o intuito de tráfico da droga apreendida dentro da unidade prisional, é devida a condenação do réu; 2. Os testemunhos de agentes penitenciários, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los; 3. Recurso não provido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3690106 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 06/04/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2016);

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Prova inequívoca de que a ré tentou ingressar com maconha no estabelecimento prisional. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. O depoimento dos agentes da lei tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um decreto condenatório. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. Isentar-se o réu da multa prevista também é medida descabida, vez que não cabe ao julgador deixar de aplicar imposição legal. No juízo da execução é que a miserabilidade do condenado pode ser examinada para fim de ser concedida a isenção ou o parcelamento. Apelo improvido. (TJ-RS - APL: 70069660983 RS, Relator: Manuel José Martínez Lucas, Data de Julgamento: 24/08/2016, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2016).

Conforme se evidenciou dos testemunhos prestados pelos agentes penitenciários, em revista de rotina levada a efeito na unidade, foi localizada na cela em que estava o acusado, no interior de uma antena da televisão porções de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha. Os depoimentos prestados pelos agentes foram firmes, harmônicos e afiguram-se idôneos e suficientes, para demonstrar com clareza a conduta ilícita levada a efeito. Agregado a isso, o próprio acusado ao ser ouvido em juízo admite que a droga era sua, da mesma forma que exposto pelas testemunhas.

Em que pese o laudo pericial de fls. 420-423 tenha apontado o acusado como dependente químico, das suas conclusões verifico que o réu tinha total consciência da ilicitude de seu comportamento. Além do mais, em razão da quantidade da substância apreendida e a forma como estava acondicionada, entendo que a mesma

destinava-se à comercialização e não ao uso, porquanto a quantidade apreendida é elevada e suficiente para produzir até 50 cigarros de maconha. Em suma, o acervo probatório mostra-se idôneo e apto a comprovar o envolvimento do acusado na prática do crime, que com sua conduta, de ter em depósito 51,92 gramas de maconha no interior do estabelecimento prisional, incorreu na prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sabe-se que o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não sendo exigida a venda de entorpecente a terceiro para que ocorra a consumação deste delito. Posto isto, a dependência química, por si só, não impede que o réu incida na prática do crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, entende a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. ÉDITO CONDENATÓRIO AMPARADO POR PROVAS, TESTEMUNHOS E DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Na hipótese, carece o apelante de interesse recursal ao insurgir-se pela fixação de parâmetro já observado na sentença recorrida (fixação da pena-base no mínimo legal). II - JUÍZO DE CONDENAÇÃO. NARCOTRAFICÂNCIA. Quando os elementos contidos nos autos de prisão em flagrante são corroborados em Juízo por declarações firmes e coerentes dos Policiais Militares que participaram da prisão do réu, forma-se, em regra, um conjunto probatório sólido e suficiente para a formação do juízo de condenação (notadamente quando a versão defensiva resta isolada nos caderno processual). Uma vez confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, resta afastada a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio, mesmo quando comprovada, por laudo pericial, a dependência química. III - TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO. Conquanto o § 4.º do art. 33 da Lei Antidrogas não estabeleça quais os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de diminuição da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias pacificaram o entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução. A apreensão de 50,70 gramas de crack (aproximadamente 400 porções individuais da droga), não autoriza a pretendida redução máxima da reprimenda (2/3), dado o alto grau de nocividade à saúde do entorpecente e, ainda, da quantidade apreendida. Recurso desprovido. (TJ-SC - APR: 00118168920188240038 Joinville 0011816-89.2018.8.24.0038, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 11/02/2020, Terceira Câmara Criminal)

Considerando que o crime ocorreu dentro de estabelecimento prisional, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é maior, a denotar uma maior audácia e destemor do acusado, posto que nem mesmo a restrição de sua liberdade em estabelecimento destinado à sua ressocialização e de vigilância constante, foi capaz de frear seu ímpeto criminoso, na medida em que continua a cometer crimes mesmo já estando a cumprir sanção penal. Assim, entendo por bem majorar a pena do acusado em metade, o que se mostra proporcional e razoável à gravidade de sua conduta, diante de seu total desrespeito pela figura do Estado. Assim entende a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RESOLUÇÃO 890/2019. VARA DE INQUÉRITOS. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM O

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª VARA CRIMINAL DE CONTAGEM. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E PRECLUSÃO. INQUIRIRÃO DAS TESTEMUNHAS PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA DE TRÁFICO. CONSUMAÇÃO COM O TRANSPORTE. FRAÇÃO DO ART. 40, III DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO. CUSTAS. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 1. A Resolução 890/2019 criou nova Vara em Contagem, competente para análise de feitos de Violência Doméstica e Familiar contra mulher e de Inquéritos. Cessada a fase das investigações preliminares e não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecida a denúncia, a causa deve ser distribuída dentre as varas criminais da comarca. 2. O TJMG tem atribuição para dispor sobre a organização judiciária no Estado, buscando maior efetividade e celeridade no julgamento das demandas. 3. Inexiste irregularidade ou perplexidade no encaminhamento do feito para distribuição entre varas criminais, igualmente competentes, pois a Vara de Inquéritos tem competência delimitada pelo oferecimento da denúncia, em casos que não se tratam de violência doméstica. 4. A inquirição das testemunhas diretamente pelo juiz e antes das partes constitui nulidade de natureza relativa, que reclama a prova do prejuízo para ser declarada. Ausente prejuízo, não se declara a nulidade. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, impõe-se a manutenção da condenação da acusada pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, revelando-se incabível a absolvição. 6. Tratando-se o tráfico de crime de conteúdo múltiplo e forma variada, o transporte da droga consome o delito, ainda que o fim visado pela ré fosse entregá-la a terceiro, dentro da Penitenciária, e não tenha alcançado seu objetivo final, que seria mero exaurimento da conduta. 7. A aplicação de fração superior à mínima, na causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/2006, se justifica em virtude de a acusada ter ingressado em Penitenciária de Segurança Máxima, denotando maior destemor de sua conduta, todavia, a fração intermediária de 1/2, mostra-se mais proporcional, suficiente e necessária, não só a reprovação do crime, mas visando também à ressocialização da agente, do que a máxima de 2/3. 8. Presume-se a hipossuficiência da agente defendida pela Defensoria Pública, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. (TJ-MG - APR: 10079190180889001 Contagem, Relator: Márcilio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021). Considerando que o crime ocorreu dentro de estabelecimento prisional, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é maior, o que denota uma maior audácia deste, uma vez que nem mesmo a restrição de sua liberdade foi capaz de frear seu ímpeto criminoso, já que continua a cometer crimes mesmo já estando a cumprir sanção penal. Assim, entendo por bem majorar a pena do acusado em metade, o que se mostra proporcional e razoável à gravidade de sua conduta, diante de seu total desrespeito pela figura do Estado. Assim entende a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RESOLUÇÃO 890/2019. VARA DE INQUÉRITOS. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª VARA CRIMINAL DE CONTAGEM. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E PRECLUSÃO. INQUIRIRÃO DAS TESTEMUNHAS PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA DE TRÁFICO. CONSUMAÇÃO COM O TRANSPORTE. FRAÇÃO DO ART. 40, III DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO. CUSTAS. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 1. A Resolução 890/2019 criou nova Vara em Contagem, competente para análise de feitos de Violência Doméstica e Familiar contra mulher e de Inquéritos. Cessada a fase das investigações preliminares e não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecida a denúncia, a causa deve ser distribuída dentre as varas criminais da comarca. 2. O TJMG tem atribuição para dispor sobre a organização judiciária no Estado, buscando maior efetividade e celeridade no julgamento das demandas. 3. Inexiste irregularidade ou perplexidade no encaminhamento do feito para distribuição entre varas criminais, igualmente competentes, pois a Vara de Inquéritos tem competência delimitada pelo oferecimento da denúncia, em casos que

não se tratem de violência doméstica. 4. A inquirição das testemunhas diretamente pelo juiz e antes das partes constitui nulidade de natureza relativa, que reclama a prova do prejuízo para ser declarada. Ausente prejuízo, não se declara a nulidade. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, impõe-se a manutenção da condenação da acusada pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, revelando-se incabível a absolvição. 6. Tratando-se o tráfico de crime de conteúdo múltiplo e forma variada, o transporte da droga consuma o delito, ainda que o fim visado pela ré fosse entregá-la a terceiro, dentro da Penitenciária, e não tenha alcançado seu objetivo final, que seria mero exaurimento da conduta. 7. A aplicação de fração superior à mínima, na causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/2006, se justifica em virtude de a acusada ter ingressado em Penitenciária de Segurança Máxima, denotando maior destemor de sua conduta, todavia, a fração intermediária de 1/2, mostra-se mais proporcional, suficiente e necessária, não só a reprovação do crime, mas visando também à ressocialização da agente, do que a máxima de 2/3. 8. Presume-se a hipossuficiência da agente defendida pela Defensoria Pública, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. (TJ-MG - APR: 10079190180889001 Contagem, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021).

Portanto, considerando a quantidade da substância apreendida, de 51,92g gramas, entendo que a mesma revela-se incompatível com o uso, a denotar que destinava-se à comercialização. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria comprovadas pela apreensão das substâncias entorpecentes (10 tijolinhos de maconha, pesando 27,30 gramas), em porções pronta para a venda, dispensadas pelo réu quando do fato, em local de tráfico, quantidade incompatível com o mero consumo próprio e com as condições econômicas do réu, que não demonstrou exercer qualquer atividade lícita, evidenciando a destinação da droga ao tráfico ilícito. (...) A circunstância de ser o acusado, também, usuário de drogas não afasta a prática do delito. Desnecessária, nesse contexto, prova presencial da mercancia. O regime inicial, em face da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, reconhecida pelo STF, deve observar o disposto no art. 33 do CP, estando, na espécie, justificado o regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, \a\, do CP. Apelo improvido. (TJ-RS - ACR: 70049990120 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 15/12/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2016);

Apelação criminal - Tráfico de drogas- Sentença condenatória. Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no mínimo legal, em face da inexistência de maus antecedentes, bem como de aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e, finalmente, de fixação de regime inicial aberto, considerando-se o período em que ficou preso provisoriamente. Materialidade e autoria comprovadas- Prisão em flagrante delito. Apreensão de 27 invólucros de maconha com o réu (peso: 26,27 gramas). (...) Não aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que a quantidade da droga e as circunstâncias evidenciam que o réu se dedicava à atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido, por ser o único compatível com o delito em tela. (...). (TJ-SP - APL: 00095761320148260071 SP 0009576-13.2014.8.26.0071, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 27/10/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2016).

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser "necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59

do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (art. 42).

No caso, o delito é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

DOSIMETRIA

1ª FASE. PENA BASE

Na primeira fase, verifica-se que o acusado possui antecedentes, pois devidamente condenado nos autos do processo de nº 0001076-82.1991.8.26.0161, conforme se verifica de certidão de fls. 475-477. Inexistem informações nos autos sobre sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias são inerentes ao crime. Por sua vez, a natureza e quantidade das drogas corroboram a caracterização do tráfico, devendo ser valoradas na terceira fase e para a fixação do regime. Diante do exposto, considerando os antecedentes do acusado, a pena-base deve se afastar do mínimo legal. Assim, exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 5 anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

2ª FASE. PENA INTERMEDIÁRIA

Inexistem circunstâncias atenuantes, porquanto o acusado apenas admitiu ser usuário da substância, não tendo confessado a prática do ilícito. Incide a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do código Penal, na medida em que o acusado foi condenado pela prática de crime por sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0083638-76.2005.8.26.0576 e cumpriu pena há menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado nesse momento. Diante disso, agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

3ª FASE. PENA DEFINITIVA

Na terceira fase, as circunstâncias do fato, ou seja, a expressiva quantidade de droga encontrada e a prática do crime no interior de unidade prisional, local de constante vigilância, indicam que o acusado se dedicava ao tráfico com habitualidade. Ademais, o acusado ostenta antecedentes e é reincidente, o que indica envolvimento corriqueiro e habitual na prática de crimes, a exigir o afastamento da caracterização do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06). Sobre o assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU QUE É REINCIDENTE E OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. (...) Assim, tendo em vista que o incremento de 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa foi indevido, a pena intermediária deve ser redimensionada para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pena que deve ser mantida na terceira etapa, vez que não incide, na espécie, a minorante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, não preenchendo, portanto, os requisitos legais. 5. Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, II, III, do Código Penal, vez que a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0117554-52.2016.8.06.0001, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 23 de julho de 2019 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator (TJ-CE - APL: 01175545220168060001 CE 0117554-52.2016.8.06.0001, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 23/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2019);

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06)- SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO ACOLHIMENTO - NÃO PREENCHIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS

REQUISITOS AUTORIZATIVOS - RÉU OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE, ALÉM DE EXISTIREM DENÚNCIAS SOBRE O SEU ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO - DOSIMETRIA MANTIDA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0007170-40.2018.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Desembargador Carvílio da Silveira Filho - J. 31.08.2020) (TJ-PR - APL: 00071704020188160044 PR 0007170-40.2018.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 31/08/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2020);

É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos são elementos que, associados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp 1624502/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020);

Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. (AgRg no HC 638.977/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021);

In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas (02 tablets e 28 porções menores de maconha, 13 pinos de cocaína e 56 porções de crack - e-STJ fl. 31), mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (AgRg no HC 631.293/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021);

As instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, consideraram, com base nos elementos concretos constantes dos autos, que as circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico de drogas não se compatibilizariam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao narcotráfico, o que afasta a pretendida incidência do redutor descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg nos EDcl no HC 611.066/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).

Presente a causa de aumento de 1/6 a 2/3 referente à prática de tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional (art. 40, III, da Lei 11.343/06). Como o acusado foi flagrado na posse de droga dentro da unidade prisional (e não nas imediações), entendo que sua conduta se torna mais reprovável, motivo pelo qual se justifica a aplicação da fração de aumento em metade (1/2), o que resulta em 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e o pagamento de 1020 dias-multa, pena que torno definitiva

VALOR DO DIA MULTA

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Cabe reconhecer que o delito cometido é equiparado a hediondo (art. 2º da Lei 8.072/90 e Súmula 510 do STJ), mas a hediondez por si só não justifica a imposição de regime fechado (Tema 972 da repercussão geral do STF), surtindo efeitos apenas na esfera de execução da pena. Pela presença da gravidade concreta da conduta, dada pelos elementos expostos na terceira fase da dosimetria, em especial, pelo crime ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional, e considerando a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, deve ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, na forma do art. 33, §2º, a, do Código Penal, Súmula 269 do STJ (analogicamente) e Súmula 719 do STF.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pelo montante da pena (maior que 4 anos), incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DETRAÇÃO (art. 387, §§ 1º e 2º do CPP)

O acusado não se encontra recluso, inexistindo motivos para que, no presente momento, seja determinada a restrição cautelar de sua liberdade em razão do presente feito. Considerando que não respondeu ao processo em reclusão, não há que se falar na incidência do quanto disposto no art. 387, §2º, do CPP.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA à pena de 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, e ao pagamento de 1020 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c. c. art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários, se for o caso.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se o mandado, a guia (art. 467 a 474 das NSCGJ), os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ) e a certidão de honorários ao defensor nomeado pelo convênio (em sendo o caso).

Com o trânsito, proceda-se com a destruição da substância apreendida, e amostras, caso ainda existentes, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/2006.

P.I.C.

Paulo de Faria, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA